

1500088-94.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON WELLINGTON ARRUDA ALVES DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

JACKSON WELLINGTON ARRUDA ALVES DA SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500088-94.2022.8.26.0550 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-94.2022.8.26.0550 - 2022/000118

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON WELLINGTON ARRUDA ALVES DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

JACKSON WELLINGTON ARRUDA ALVES DA SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº

11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 11:49 horas, na Estrada da Bomba, nº 758, esquina com Rua 11, Vila Santa Teresinha, nesta Comarca, as fls. 04/05 e 07/09, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito, 01 (um) frasco contendo a substância entorpecente denominada tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 58,05 gramas, e mais 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos contendo a mesma substância entorpecente, totalizando peso líquido de 1.598,38 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 e laudo de constatação de fls. 30/32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 06 de junho de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu o parcial acolhimento da pretensão acusatória, com o afastamento tão somente da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, com majoração posterior decorrente da recidiva, impossibilitando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, também em função da evidenciada dedicação criminosa, com imposição de regime prisional inicial fechado, além da pena de perdimento dos valores apreendidos, porque decorrente da atividade criminosa. Já o ilustre Defensor inicialmente observou que a apreensão do entorpecente decorreu de procedimento ilícito, com invasão de domicílio, comprometendo a materialidade delitiva, a determinar a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dizendo insuficiente a prova produzida no que diz com a destinação mercantil do entorpecente, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente pugnando pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, inclusive para compensá-la com a agravante da reincidência, seguindo-se a redução em decorrência do previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em grau máximo, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede em parte a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 139/140, identificando-se na substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha.

Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida diante da ilícita apreensão do entorpecente, decorrente de violação de domicílio.

Entretanto, respeitado o entendimento exposto, não se entende tenha ocorrido a mácula apontada.

Como exposto pelos Policiais Militares que realizaram a apreensão, na ocasião havia denúncia de que no local indicado estava ocorrendo a prática do denominado "tribunal do crime", com a presença no imóvel de cinco indivíduos armados e um outro clamando por socorro. Diante disto, acorreram àquele local, onde mantiveram contato inicial com o acusado, que se apresentou como o morador, tendo ele negado a presença de outros indivíduos no imóvel. Esclarecido sobre a denúncia recebida, franqueou o ingresso na moradia, onde se constatou a existência de um pote de vidro, sobre uma cômoda, contendo maconha, além de outras porções da mesma

substância entorpecente no interior da geladeira, compondo aproximadamente 1,5 kg. Deste modo, o ingresso no imóvel se deu mediante autorização do acusado, que por lá disse residir. Além disto, a denúncia anteriormente recebida cogitava da ocorrência de um delito de natureza permanente, com possível sequestro e tortura, culminando na apreensão de significativa quantidade de entorpecente e petrechos indicativos do comércio ilícito, excepcionando a inviolabilidade do domicílio.

Controverte-se sobre a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em juízo, o acusado afirmou que na ocasião dos fatos estava no interior de sua moradia, quando foi chamado ao portão, tratando-se de Policiais Militares que o alertaram sobre a possível presença de indivíduos armados no interior do imóvel, sendo então derrubado ao solo, seguindo-se o ingresso no imóvel, com a apreensão do entorpecente que mantinha para o próprio uso. Esclareceu ainda que o dinheiro apreendido, no valor aproximado de quatro mil reais, decorria da sua atividade como "chapa". Por fim, afirmou que as embalagens plásticas igualmente apreendidas eram descartes do entorpecente consumido e que a balança de precisão pertencia à sua genitora, que utilizava para pesar a droga adquirida.

Todavia a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Policiais Militares ouvidos, reiterando em juízo o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que na ocasião receberam denúncia de que no local indicado estava ocorrendo a prática do denominado "tribunal do crime", com a presença no imóvel de cinco indivíduos armados e um outro clamando por socorro. Diante disto, acorreram àquele local, onde mantiveram contato inicial com o acusado, que se apresentou como morador, tendo ele negado a presença de outros indivíduos no imóvel. Esclarecido sobre a denúncia recebida, franqueou o ingresso na moradia, onde se constatou a existência de um pote de vidro, sobre uma cômoda, contendo maconha. Indagado sobre o entorpecente, o acusado afirmou que era usuário e revelou a existência de outras porções no interior da geladeira, compondo mais de sessenta e cinco porções, com peso aproximado de mil e quinhentos gramas. Além disto, no interior do imóvel foram apreendidas várias embalagens plásticas semelhantes àquelas que embalavam a droga, balança de precisão e quantia aproximada de quatro mil reais. Afirmou o acusado, por fim, que o entorpecente era oriundo do Estado do Paraná e vendia as porções via aplicativo whatsapp, com observação de que o dinheiro apreendido decorria do comércio ilícito.

Como se tem consagrado, à míngua de qualquer elemento probatório que indique algum abuso, não se pode presumir que os policiais militares estivessem animados do propósito de incriminar indevidamente o acusado. Sobre isto: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Ademais, a emprestar ainda maior idoneidade ao que exposto pelos Policiais

Militares, não apenas se apreendeu no local quantidade expressiva de entorpecente, já composta em várias porções, mas também embalagens plásticas semelhantes àquelas que as embalavam, além de uma balança de precisão, a amparar a indicação de que o acusado estava realizando o comércio ilícito. Ademais, também no local se apreendeu valor significativo em dinheiro, não havendo nenhuma comprovação da origem, cujo ônus competia ao acusado, ao dizer que decorria de atividade laborativa.

Deste modo, os elementos probatórios, reveladores da posse e da destinação mercantil, possibilitam seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, sendo incontornável o acolhimento da pretensão acusatória, mas não integralmente.

É que, como reconhecido pelo Parquet, deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, porquanto não demonstrado que o acusado estaria promovendo o tráfico interestadual.

Por fim, diante da apreensão de valores cuja origem não foi confirmada, havendo indicação de que o acusado chegou a afirmar inicialmente que decorriam da atividade ilícita, deve incidir sobre a quantia apreendida a pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, embora expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, era de menor potencial lesivo (maconha), devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena-base deve ser agravada, entretanto, em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva (fls. 56/57), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a consideração da recidiva também neste momento, tem-se por obstada objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado JACKSON WELLINGTON ARRUDA ALVES DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser considerada a recidiva e também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênica, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer

tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras. Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008). E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA